

· 全面依法治国研究 ·

爱国主义法治建设的理论逻辑与实施体系

杨清望*

摘 要：依法传承和弘扬爱国主义精神是促进人民国家认同的必然要求，也是实现人民理性爱国的有效保障。“中国”作为一个历史文化和政治法律概念的综合体，为人民爱国提供了深层的文化根源和现实的法律依据。爱国行为的法律内涵包括维护之爱、服从之爱和参与之爱。加强爱国主义法治建设，具有深刻的法理基础和制度资源：一方面，爱国主义法律义务框定了爱国行为的内容及其边界；另一方面，爱国主义立法、执法、司法及守法积聚了丰富的实践经验，但也存在诸多不足。当前，加强爱国主义法治建设，应当健全爱国主义法律规范体系、构建刚柔并济的双层爱国主义行政执法机制、积极拓展“上下联动”的爱国主义司法保障机制、以“防范风险+完善激励+包容发展”为支点健全爱国主义守法机制，最终形成制度合力，推动爱国主义法治实施和爱国主义理性发展。

关键词：爱国主义；法治建设；法律义务；制度资源；实施体系

引 言

习近平总书记指出：“实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神，以改革创新为核心的时代精神。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魂。”^①但近年来，社会上多次出现故意歪曲、丑化、侮辱、否定英雄烈士事迹和精神以及宣扬历史虚无主义的行为，这些行为严重伤害了民族感情和民族精神；与此同时，社会上还出现了一些借“爱国主义”之名裹挟公共舆论的现象。这两种极端思潮都会扩大社会对抗、削弱社会凝聚

* 中南大学法学院教授、博士生导师，中南大学人权研究中心、中南大学文化遗产研究院研究员。
本文系国家社会科学基金重点项目“社会主义核心价值观与国家荣誉、纪念、庆典法治建设的研究”（17AHJ002）、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“新时代中国特色人权保护和发展模式对人权理论的发展研究”（22JJD820047）的阶段性成果。西南大学陈庆博士对本文希腊语部分进行了修校，特此致谢！
① 习近平：《大力弘扬伟大爱国主义精神，把强国建设、民族复兴伟业不断推向前进》，《求是》2024 年第 19 期，第 4 页。

力、损害国家形象，并侵蚀中国式现代化的精神动力。显然，加强爱国主义法治建设，在法治轨道上推动理性爱国，实现爱国主义科学化、长效化，已经成为迫切而重大的时代问题。

“爱国主义”是起源于18世纪的一个政治哲学和道德哲学概念。从词源上看，它来源于“patriot”（爱国者）一词，其词根是“patria”（祖国）。^②“patriot”（爱国者）一词又最早来源于古希腊语“πατριώτης”和“πατρίς”。“πατριώτης”是与“πολίται（公民们）”相对的概念。古希腊人用“πολίται（公民们）”指称“有共同‘邦国（πόλις）’的人”，而用“πατριώτης”指称“仅有共同‘祖地（πατρίς）’的人”。“πολίται”属于褒义词，是希腊人用来自我描述的词；而“πατριώτης”是一个贬义词，是希腊人用来刻画番邦人的词。^③“πατρίς”的含义为“祖辈居住过的土地”，即“fatherland”。^④公元6世纪，“πατριώτης”和“πατρίς”演变为拉丁语“patriota”，其含义为“countryman”，即“同胞或者国人”。随后，“patriota”经德文而被英文吸纳为“爱国主义”一词，对国家的情感认同和身份归宿成为其最基本的思想内核。时至今日，“爱国主义”已经成为全人类的共同价值。在西方，“爱国主义是政治理想万神殿中的核心概念之一”。^⑤进而，为依法保证爱国主义的正向发展，当代西方学者秉持爱国主义与公民美德关系的解释框架，形成了以哈贝马斯所提出的“宪法爱国主义”为代表的理论模式，该理论模式强调可以从人们共同制定的宪法及其政治秩序中找到实现国家认同和社会整合的模式。^⑥而在中国，家国情怀一直是中华文明生生不息的动力。习近平总书记指出：“爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。”^⑦近代以来，中华儿女展开了艰苦卓绝的救亡图存运动。特别是自中国共产党成立以来，中国共产党领导中国人民进行革命、建设和改革，不仅实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大转变，而且形成了不同时期下丰富的爱国主义实践和思想。^⑧当下，爱国不仅已经成为社会主义核心价值观的重要内容，而且成为公民个人层面的首要价值。

然而，爱国主义首先是一种爱国情感甚至意识形态，体现为个人对自己国家认同和支持的态度。爱国主义本质上属于道德范畴，但当法治介入爱国主义的保护和促进时，就赋予了爱国主义坚实的规范基础和必要的强制力量。那么，弘扬爱国主义精神为什么必然诉诸法治？爱国主义与法律及法治之间如何建立起内在关联？爱国主义法治建设应该如何展开又何以可能反哺爱国主义？尽管学界已在此领域取得了一系列研究成果，我国也初步建立了爱国

② See Mary Golden Dietz, “Patriotism: History and Politics of a Keyword”, in Mitja Sardoc (ed.), *Handbook of Patriotism*, Springer Nature Switzerland AG Press, 2020, p. 10.

③ See Henry George Liddell, Robert Scott and Gregory Crane, *A Greek-English Lexicon*, Oxford University Press, 1996, p. 1349.

④ 与“πατριώτης”和“patriot”相关的论述参见 Plat. Laws 777c；与“πατρίς”和“fatherland”相关的论述参见 Xenophon. Cyrop. 2. 2. 26, Xenophon. Cyrop. 8. 5. 21.

⑤ See Mitja Sardoc, “Patriotism and Its Critics”, in Mitja Sardoc (ed.), *Handbook of Patriotism*, Springer Nature Switzerland AG Press, 2020, p. 3.

⑥ See Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, translated by William Rehg, Polity Press, 1992, pp. 499–500, 507.

⑦ See George Kateb, *Patriotism and Other Mistakes*, Yale University Press, 2006, p. 3.

⑧ 参见温静：《中国共产党爱国主义思想史略》，人民出版社2019年版，第4页。

主义教育法律法规体系,^⑨但是针对爱国主义法治建设这一问题的深入研究和系统推进仍显不足。爱国主义法治建设在价值层面关涉维护国家主权和国家认同的重大问题,在制度层面关涉国家(政府)、社会和人民等多个主体的权利与义务、权力与职责的配置问题,因此,需要在法治框架下对爱国主义立法、执法、司法和守法等环节进行学理分析和系统设计。有鉴于此,本文试图从规范主义的进路出发,首先,通过澄清爱国行为的内涵,释明其价值功能,揭示爱国主义与法治的内在关联;其次,在理论上证成爱国主义法律义务,并分析其具体类型,从而为爱国主义法治体系建设提供科学的法理依据;最后,全面梳理爱国主义法治建设的制度资源及其不足,为完善爱国主义法治实施体系提出具体建议。

一、爱国主义法治的内涵阐释

通过法治来保障和促进爱国主义,需要在规范和价值的意义上回答如下基本问题:爱国行为的法律内涵是什么?爱国主义与法治的内在关联是什么?

(一) 爱国行为的语义分析

将爱国行为纳入法律调整范围,需要回答两个问题:爱国行为的法律保护对象是什么?这是划定法益类型及其归属主体的前提。爱国行为有哪些类型?这是对其进行法律保护的可行性基础。

1. 爱国行为法律保护“对象”之内涵:“中国”的实质与实体

“中国”是什么?这是探讨爱国主义法治建设的逻辑起点。但如何界定“中国”的概念是一个复杂的问题。理查德·丹格尔(Richard Dagger)认为,关于“国家”这一概念存在三种解释:第一,一个人的“国家”是他的祖国或祖先的家园;第二,一个人的“国家”是他的民族;第三,一个人的“国家”是他作为公民的政治社会。^⑩“中国”作为国家的种概念,具有现代国家的一般特征,也具有自己的独特性。葛兆光指出,只有从历史、文化、政治三个角度出发,才能准确界定“中国”的概念。^⑪吸取上述理论,可以对“中国”作如下界定:

第一,“中国”是一个历史的、文化的概念,是基于“国家认同”形成的历史文化共同体。首先,从历史的角度来看,中国的历史形态经历了漫长的演化过程。我国《宪法》在序言部分指出,中国经历了从封建的中国到中华民国再到中华人民共和国的历程。这一历程不仅是对我国社会发展之历史形态的基本描述,也代表我国的文化属性在国家政权名称上得到了宪法承认,更表达了两岸同根同源、同文同种的血脉相连关系。其次,从文化的角度来看,“大一统”文化和“国家认同”是中国文化的内核。中国的“大一统”文化贯穿于主权中国的不同历史形态之中。葛兆光指出,“中国”兼有现代国家与传统国家的复杂性。秦汉

^⑨ 参见杨清望:《文化法治体系的法理意蕴与实践展开》,《中国法学》2025年第1期,第101页。

^⑩ See Richard Dagger, “Patriotism and Republicanism”, in Mitja Sardoč (ed.), *Handbook of Patriotism*, Springer Nature Switzerland AG Press, 2020, p. 91.

^⑪ 参见葛兆光:《宅兹中国——重建有关“中国”的历史论述》,中华书局2011年版,第31-33页。

以来，政治文化意义上的传统中国不断叠加和凝固成为现代中国。^⑫从理论上来说，秦汉以来，整个世界都可以被纳入“天下”的范围之内。“天下”观本质上是一种政治哲学理论，其将“世界”看作一个最大并且最高的政治单位，认为“世界”是一个思考所有社会、生活问题的思想分析框架，即最大的情景或解释条件。^⑬直到1895年之后，受西方思想影响，中国传统的“天下”概念开始崩塌，“万国”概念得以确立。但中国的“大一统”文化得以保留，其作为“多重型天下国家观”，奠定了绵延至今的多民族统一国家的思想基础。^⑭与西方国家追求民族自决权不同的是，中国追求的是中华民族共同体这一理念。中华民族共同体不是所谓“想象的共同体”，其概念是基于对历史的事实性陈述而产生的，维护国家统一是中华民族共同体最大的共识。例如，在家之孝与对国之忠是中国五千年不断裂文明中的重要理念。^⑮这种国家认同文化内嵌于中华民族共同体的历史意识和政治传统之中，表现出了超强的稳定性和可继受性，并在不断吐故纳新中沉淀为中华民族的优良传统，支撑和维系着中华文明的绵延和发展。

第二，“中国”是一个政治的、法律的概念，是宪法及法律所确认的主权国家。首先，从政治的角度来看，“中国”是现代意义上的主权国家。现代国家观念立基于马基雅维利与霍布斯的国家理论、洛克的政府论以及卢梭的社会契约论。现代国家意指在确定的领土范围内，通过人民一致同意建立最高主权，由政府机构垄断合法性权力并行使权威的共同体。主权在民合乎逻辑地要求人民爱国。其次，从法律的角度来看，“中国”是在内部由宪法自我确认主权、在外部得到国际法认可的主权实体。政治意义上的中国与宪法及法律意义上的中国不可分割、相辅相成，因为政治意义上的现代主权国家必然要求法律的确认和保护。在现代世界体系中，一个“国家”必须具备领土、国民、政府和国际法承认等要素。^⑯前三个要素是国家主权的标志，后一个要素是国家主权在国际法上得到确认的体现。由此可见，当前在政治和法律上代表主权中国的实体就是中华人民共和国。

2. 爱国行为的法律内涵：“爱”的层次与形式

究竟何为对国家的“爱”？一般认为，爱国行为的规范内涵涉及国家和公民两个维度下的四个要素，即国家德性、国家能力、公民身份、公民参与。^⑰具言之，学界一般认为，爱国主义指称如下几层意思：其一，公民对自己国家的特殊感情，包括归属感和感激之情。其二，公民对国家的认同感。认同包括对一国主权的认同及其价值观念、制度、历史和文化等因素的认同。其三，公民特别关注国家的福祉。其四，公民为促进国家的利益，甘愿自我

^⑫ 参见葛兆光：《历史中国的内与外：有关“中国”与“周边”概念的再澄清》，香港中文大学出版社2017年版，第128-130页。

^⑬ 参见赵汀阳：《“天下体系”：帝国与世界制度》，《世界哲学》2003年第5期，第5页。

^⑭ 参见王旭：《大一统国家观的中国宪法学原理》，《法制与社会发展》2022年第6期，第23页。

^⑮ 参见刘庆柱：《不断裂的文明史：对中国国家认同的五千年考古学解读》，四川人民出版社2020年版，第423页。

^⑯ 参见葛兆光：《历史中国的内与外：有关“中国”与“周边”概念的再澄清》，香港中文大学出版社2017年版，第123页。

^⑰ See Polycarp A. Ikuenobe, “Citizenship, Patriotism, and Liberal Morality”, in Mitja Sardoc (ed.), *Handbook of Patriotism*, Springer Nature Switzerland AG Press, 2020, pp. 318-321.

牺牲。^⑮ 结合主权国家的法律基础,爱国行为的法律内涵可以被分解为三个方面。

其一,公民基于国家主权绝对性产生的对国家的“维护之爱”。认同和维护国家主权是爱国主义的根本内容。“国家主权原则不仅指向国家主权的独立和平等,而且涵盖国家政权、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益等内容,这在新时代发展为总体国家安全观。”^⑯ 公民爱国表现为捍卫自己国家的主权,特别是绝对维护国家的历史文化,领土,立法、行政、司法权力,以及国家发展利益。正因如此,在国家主权被侵犯的时候,公民的爱国情感表现得最为明显和激烈。从依据上看,我国《宪法》第2条确立了人民主权原则。因此,国家、个人和其他社会主体在利益上是一致的,国家应为公民基本权利的实现提供条件;同时,公民也要为国家的发展承担一定的义务或责任。^⑰

其二,公民基于主权国家是国内法秩序所确认的合法性存在,从而产生的对宪法及法律的“服从之爱”。“主权国家仍然是支撑宪法秩序与国际秩序的基础,国家对于宪法与法律制度的构建发挥着不可或缺的作用。”^⑱ 主权是对国家客观存在的理论抽象,宪法及法律是理解国家主权内涵和公民行动的规范依据。遵守国家宪法及法律的义务或者责任是国家统治权力的基石,也是以宪法统领国家法秩序的必然要求。因此,公民对国家的爱也就是对宪法及法律的尊重与维护。

其三,公民基于参与国家治理和社会事务而对国家政权机关产生的“参与之爱”。国家的目的在于促进和实现“共同善”,但国家本身并没有行动能力,因而需要组建政府等政权机关来制定和执行公共决策。换言之,政权机关是代表国家行使主权的工具。“参与之爱”的内涵是指公民通过协商式民主参与国家治理和社会事务。我国《宪法》序言和第二章分别规定了政治协商制度和公民基本权利,这为公民对国家的“参与之爱”提供了宪法依据。公民通过协商式民主参与公共决策的过程,不仅能够确保政府行动的合目的性,也可以监督权力的运行,从而避免权力的滥用和异化。公民参与公共决策的过程有利于促使公民理性爱国。但需要强调的是,由于政府是由具体的人和官僚系统来维持运作的,因此,可能会产生权力异化现象。基于此,公民对政府等政权机关的爱应当被限定在国家目的的范围之内。

综上所述,从爱国行为的法律内涵来看,爱国行为是“维护国家主权,服从宪法法律,参与国家治理”三种内容的耦合。其中,“维护之爱”是爱国行为的基础内容和底线要求。“维护之爱”涉及对国家主权、领土完整的保护,为爱国主义提供了根本的出发点和情感基础。“服从之爱”是爱国行为的核心内容,是实现“维护之爱”的保障,其反映了个体对国家法秩序的认同,是公民将爱国情感转化为实际行动的表现。“参与之爱”要求公民积极参与到国家治理和公共事务中,是实现公民理性爱国的基本保障。这三个层面的爱国行为的法律内涵,体现了从“底线维护”到“主动参与”的层级式要求,构成了理解爱国主义内容的法律依据。

(二) 爱国主义与法治的内在关联

^⑮ See Nathanson Stephen, “In Defense of ‘Moderate Patriotism’”, *Ethics*, Vol. 99, No. 3 (1989), pp. 548–550.

^⑯ 王理万:《主权原则在中国宪法中的展开》,《中国法学》2023年第6期,第158页。

^⑰ 参见张翔:《基本权利的规范建构》,法律出版社2017年版,第56页。

^⑱ 韩大元:《论香港基本法上“国家”的规范内涵》,《中外法学》2020年第1期,第19页。

由于爱国主义关涉国家、社会和个人之间的多方关系，因此，通过宪法及法律明确各方的权利义务、权力职责关系，进而通过法治方式维护社会共识和消解分歧就成为必然。特别是随着全球化的发展，如何通过宪法及法律来推行爱国主义就变得更加重要。一批学者讨论了以宪法为认同纽带塑造国家认同的重要性，并主张“国家认同应当从历史、文化、民族等原生性认同向基于公民身份和公民权的宪法认同转变”。^{②②} 具言之，爱国主义需要通过宪法和法律来得到申明，同时应防止爱国主义滑向正反两个极端。

第一，爱国主义所蕴含的社会底线价值需要宪法及法律来确立。所谓社会底线价值，就是全人类共同价值，它包括和平、发展、公平、正义、民主、自由。“‘全人类共同价值’集中体现了 21 世纪法治文明的精髓和要旨……全人类共同价值引领法治文明新方向，创造法治现代化新道路。”^{②③} 在我国，社会主义核心价值观与全人类共同价值在内容上相辅相成，共同发挥着沟通法律和道德、世界与中国的桥梁作用。习近平总书记指出：“在社会主义核心价值观中，最深层、最根本、最永恒的是爱国主义。”^{②④} 即使在西方，爱国主义主张也是一种重要的理论力量。例如，美国的斯蒂芬·内桑森教授提出了温和爱国主义的观点，该观点认为，公民有权抒发对自己国家的特殊感情以及表达对自己国家的特殊但非排他性的关注，并支持公民在道德的约束下追求国家目标。^{②⑤} 因此，以宪法及法律维护爱国主义也要求公民依法践行和弘扬社会主义核心价值观。

第二，爱国主义的基本标准和范围需要宪法和法律来规范。由于“可见性是践行爱国主义的第一要义”，^{②⑥} 因此，需要通过法律来确保爱国行为的理性，防止爱国的盲目化。可以说，真正的爱国者必须是有思想的爱国者，如果没有法律的限定，那么任何美德都有堕落成恶习的可能。然而，传统观点认为，爱国主义的基本标准和范围应该交由政策而非法律解决。其原因，一是法律可能会将道德的内容过度摄入，造成爱国义务的泛化；二是政策的灵活性能够更好地回应爱国义务落实中的各种问题。但是这两点担心都不成立，因为法律是社会最大范围和最大程度的共识，恰恰是法律义务的设定框定了爱国义务的标准和范围，为公民的行为提供了稳定的预期。而政策更多是一种政治权衡，其具有灵活性的特点，将政策用于经济方面非常合适，而将其用于精神层面则容易产生政策失灵现象。例如，苏联在爱国理论和政策上不断变化，导致社会思想混乱，从而造成了严重的危害后果。^{②⑦}

第三，爱国主义价值共识的凝聚需要通过法治实施来促进。爱国的本质是对国家的认同，目的是实现“共同善”。如前所述，对爱国主义的一大批评是认为爱国主义会造成排外现象，甚至会成为发起战争的理论支持。化解这一质疑的出路是以有效、充分的沟通与对话来确立爱国主义的根本价值共识。具言之，对国家认同的基础是充分尊重个体权利，只有这

②② 陈明辉：《转型期国家认同困境与宪法的回应》，《法学研究》2018 年第 3 期，第 21-38 页。

②③ 张文显：《习近平法治思想的政理、法理和哲理》，《政法论坛》2022 年第 3 期，第 20 页。

②④ 习近平：《大力弘扬伟大爱国主义精神，把强国建设、民族复兴伟业不断推向前进》，《求是》2024 年第 19 期，第 6 页。

②⑤ See Stephen Nathanson, "In Defense of 'Moderate Patriotism'", *Ethics*, Vol. 99, No. 3 (1989), p. 549.

②⑥ See Steven J. Mock, "Civic Patriotism Versus Ethnic Nationalism", in Mitja Sardoč (ed.), *Handbook of Patriotism*, Springer Nature Switzerland AG Press, 2020, p. 915.

②⑦ 参见李晓辉：《苏共爱国主义教育工作失败原因探析》，《思想政治教育研究》2010 年第 4 期，第 86-89、92 页。

样，才能确保个体可以通过平等对话来建构爱国主义的最大公约数。共同善是爱国主义的“陀螺仪”，其作用的发挥有赖于各方主体的充分对话，而“法律正扮演一个沟通党、人民与国家三者意志，最终取得共识的形式理性”。^{②⑧}因此，只有在法治的轨道上倡导爱国主义，才能确保爱国主义价值共识的形成和稳定，同时，还能够防止公民陷入虚无主义或盲目的爱国情绪，从而实现民族性与世界性的统一，保障国家实现“共同善”的目的。

二、爱国主义法律义务的理论依据

推进爱国主义法治建设的前提是设定爱国主义法律义务。那么，设定爱国主义法律义务的理论依据是什么？爱国主义法律义务又有哪些类型？对这两个问题的回答关涉爱国主义法治建设是否具有可行性。

（一）中国语境中爱国主义法律义务的理论坐标

尽管爱国主义已经成为全人类共同价值，但是，不同国家弘扬爱国主义精神的背景和面临的问题不同。设定我国的爱国主义法律义务不仅需要吸收爱国主义的全人类共同价值，更需要结合中国的文化传统和国情。

第一，设定爱国主义法律义务需要处理好个人与社会的变量关系。西方的理论往往立足于个人与国家的对立关系，而中国却具有不同于西方的文化传统和国家认知观念。首先，中国的哲学观认为，人是关系性的存在，“人本”思想是中国人爱国的底色，家国天下是一体的。其次，在鸦片战争之后，中国近代民族意识觉醒，爱国成为支撑中华儿女救亡图存的重要精神。近现代以来，中国人的对国之爱还包含了对国家主权独立的追求和对摆脱半殖民地半封建社会的自由的追求。这两个方面衍生出了当下中国语境中爱国主义的两个基本特点：第一，社会主义中国是历史的选择和人民革命的伟大成果，其所保护的是最广大人民的根本利益。在社会主义中国，个人、社会、国家的利益具有一致性。而且，中国语境中的“国家”强调为所有人的发展提供保障，并不会忽视少数人的利益。第二，爱国主义既是促使社会系统发挥功能的重要力量，也是推动社会结构正常运转的保证。爱国主义是公民基于其身份而产生的义务。在公民共同体内部，爱国主义可以促进包容、信任、合作和利他主义，这对于现代国家这样庞大而多元的社会体系的运作至关重要。^{②⑨}当今，尽管全球化不断发展，但是世界格局依然以民族国家为基石。因此，“我们需要的是保持开放的爱国主义，而不是用世界主义来代替爱国主义”。^{③⑩}

第二，设定爱国主义法律义务需要发挥好消极防御与积极促进这两种方式的协同功能。就西方国家而言，揆诸历史，在其民族国家早期，就出现了极端国家主义，并随后演变为种族主义。种族主义在二战前夕发展至顶峰，给人类带来了巨大灾难。因此，西方学者提出了宪法爱国主义理论，旨在通过保护宪法基本权利和维护多元伦理价值来实现社会平衡。概言

^{②⑧} 王旭：《“法治中国”命题的理论逻辑及其展开》，《中国法学》2016年第1期，第90页。

^{②⑨} See Richard Dagger, “Patriotism and Republicanism”, in Mitja Sardoc (ed.), *Handbook of Patriotism*, Springer Nature Switzerland AG Press, 2020, p. 87.

^{③⑩} 朱慧玲：《爱国主义的双重维度——基于公民共和主义的证成与辩护》，《哲学研究》2019年第10期，第33页。

之，西方近现代的法律叙事是围绕反对基督教神权和封建王权展开的，其主张在公权力与个人权利的对立中寻找最佳方案，强调的是法律的消极防御功能。而在中国，国家与人民是“水与舟”般相互依存的关系。只有设置爱国主义法律义务，才能实现人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感。而且，对于一个多民族国家而言，爱国主义以增进出生在或生活在同一个国家的所有人的利益为目的，具有极大涵摄性。在此意义上，爱国主义超越了狭隘的民族意识形态，具有合目的性。菲利普·佩蒂特指出：“让爱国主义占上风，就不太可能出现破坏社会规范、分裂社会的行为。”^①即使在西方国家，爱国主义也是应对政治冷漠和社会分裂的有效武器以及促进社会整合和共同体建设的黏合剂，这也为历史事实所验证。

（二）爱国主义法律义务的法理证成

从学理上看，义务必须以某种方式指导我们的行为，并为我们的行为提供理由，正当的理由是义务规范性的基本要素。^②对爱国主义法律义务的理解可以从正当性依据、法律性特征和现实性基础三个理论维度展开。

第一，从正当性依据来看，爱国主义法律义务的逻辑起点在于维护个人权利和国家共同利益的一体化。设立与履行爱国主义法律义务是实现国家目标的重要条件。一方面，主权国家作为一种“德性社群”，其目标是保障人的生存与发展，维护人的尊严与自由，这已经得到当今各国宪法和法律的普遍承认；另一方面，人的尊严和自由也依赖于国家，维护国家的共同利益是国家德性对个人的内在要求。约翰·克雷宁（John Kleinig）指出，我们的人格和特定身份是通过各种各样的互动关系而得到明确表述的。^③黑格尔指出：“在国家里，个人自由才能达致与他人、普遍自由、共同善的统一。”^④共同善的实现是国家与个体共同协力达致的结果，这要求公民在享有参与公共事务的权利的同时，也要承担维护共同善的责任。因此，在爱国主义法律义务的基础上构建爱国主义法律制度体系，既要求普通公民个体承担爱国义务、追求共同善的实现，还要求公权力主体及其工作人员积极主动为公民履行其爱国义务创造空间与条件。以爱国主义为名剥夺他人的尊严和自由，以及以人的尊严和自由否定民族国家的时代价值甚至否定民族国家的现实存在，都是需要被依法规制的错误行为。

第二，从法律性特征来看，爱国主义法律义务的外在理由是实定法体系，内在理由是法律规则“合道德性”的法理。根据哈特的观点，法律规则是融合了外在强制和内在道德的概念，由第一性规则和第二性规则构成。^⑤法律效力的直接来源是第一性规则即义务规则的明确规定，而其深层次的根源是公众对作为行为准则之义务的普遍接受。从外在强制层面来看，我国《宪法》第51、52、54、55条分别从不同角度阐述了公民的基本爱国义务。另外，具体的法律也规定了关于爱国主义应为、可为、勿为的行为模式，这些规定是对公民普遍接

① See Philip Pettit, *On the People's Terms: A Republican Theory and Model of Democracy*, Cambridge University Press, 2012, p. 262.

② See Stefano Bertea, "Contemporary Theories of Legal Obligation: A Tentative Critical Map", in S. Bertea (ed.), *Contemporary Perspectives on Legal Obligation*, Routledge Press, 2021, pp. 5-8.

③ See John Kleinig, "Loyalty and the Limits of Patriotism", in Mitja Sardoc (ed.), *Handbook of Patriotism*, Springer Nature Switzerland AG Press, 2020, p. 486.

④ [德] 黑格尔：《法哲学原理》，范扬、张企泰译，商务印书馆2011年版，第276页。

⑤ 参见[英] 哈特：《法律的概念》，许家馨、李冠宜译，法律出版社2018年版，第81-82页。

受的爱国主义行为标准和内涵的法律转化。这些规定不仅形成了统一的爱国主义法律制度体系,也为爱国主义法律义务的实现提供了依据。从内在道德层面来看,这些爱国主义法律义务也是公民作为共同体成员的道德责任,即维护国家存在和发展的“最低限度的道德”,更是国家宪法和法律制度的首要关切之一。

第三,从现实性基础来看,爱国主义法律义务是对个体与群体之间关系的实然性描述,是将共同体成员的身份义务法律化的体现。爱国主义立基于人与人作为“关系共同体”的现实,主张公民负有促进人与人共生共荣、国家繁荣和发展的义务。共同体义务强调“人与其作为成员的政治社会之间的道德伦理关系,涉及一个人作为特定整体的成员所承担的义务”。^{③⑥}从国家的政治属性来理解,共同体义务实际上就是公民应承担的政治义务。关于政治义务的正当性解释,主要有自愿论、目的论、责任论和关联义务论等观点。自愿论主张,政治义务应通过个人的自愿承诺行为来解释。^{③⑦}目的论强调,政治义务的正当性在于其有助于实现共同善(共同利益)的价值和目的。^{③⑧}责任论主张,必须通过对人们的职责进行解释来证明政治义务是合理的,这些职责既不是人们自愿承担的结果,也不仅仅是为了促进某种共同善。^{③⑨}如罗尔斯主张,政治义务源于支持和促进正义制度的自然责任。关联义务论强调,政体是一种以秩序和安全为一般价值的联合形式,政治义务属于那些提供独特而重要的善的政治共同体的成员。^{④⑩}综上所述,客观的成员资格和主观的政治认同构成了共同体成员政治义务的德性基础。就客观方面而言,政治义务主要建立在成员对政治共同体的依附之上,其强调的是公民对国家的爱与忠诚以及对国家法律秩序的遵守;就主观方面而言,国家作为“构成式社群”,赋予了公民“团结的义务”。此外,国家也是一种“德性社群”,其建构了人们的政治生活和社会公共秩序。概言之,人与人是关系性的存在,其最终的依托都是民族国家。民族国家塑造了个体的身份认同、道德感和责任意识。为了国家这一“共同体”的强大和发展,公民需要把国家或民族利益摆在首位,建立起对国家的情感认同、文化认同、政治认同,^{④⑪}这些认同表现为对社会文化、法律等制度的遵守。这就是爱国主义法律义务的现实根源。

(三) 爱国主义法律义务的主要类型

爱国主义法律义务的本质是施加给义务主体的一种负担。个体的社会身份不同,承担的义务也不同。换言之,个体的社会身份是科学划定爱国主义法律义务类型、范围及其边界的直接依据。

1. 基于文化身份的爱国文化宪法义务

所谓文化身份,是指一个人基于其民族、文化、血统等因素而具有的身份。正如前文所述,“中国”本身是一个文化的概念。就中国人而言,其共同的文化身份是中华儿女,其所

^{③⑥} See John Horto, *Political Obligation*, Palgrave Macmillan Press, 2010, p. 8.

^{③⑦} See Margaret Gilbert, *A Theory of Political Obligation*, Oxford University Press, 2006, pp. 125-126.

^{③⑧} See A. J. M. Milne, “Political Obligation and the Public Interest”, in Paul Harris (ed.), *On Political Obligation*, Routledge Press, 1990, p. 2.

^{③⑨} See Richard Dagger, David Lefkowitz, “Political Obligation”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Apr. 17, 2007), <https://plato.stanford.edu/entries/political-obligation> (last visited on February 15, 2014).

^{④⑩} See John Horto, *Political Obligation*, Palgrave Macmillan Press, 2010, p. 165.

^{④⑪} 参见唐凯麟:《试析爱国主义和经济全球化》,《道德与文明》2003年第3期,第6-7页。

属的根本社群是中华民族共同体。因此，中国人基于其文化身份而负有的爱国文化宪法义务，需要在中华民族共同体的统一属性中得到限定。首先，从积极层面来看，中国人负有传承家国文化、维护国家统一、弘扬民族精神的积极作为义务。其次，从消极层面来看，由于每一个中国人都是国家历史进程中的行动者，因此，其既有叙述历史的权利，同时又负有尊重历史真相、不得伪造历史、不得歪曲历史的不作为义务。此外，对于每一代人来说，当他们“降生于历史的程序之中，就被加上了其父辈罪恶的重担，正如他们也蒙受其先祖功勋的福泽”。^{④2} 因此，中国人还负有不得刻意美化先辈过失和不得刻意丑化先祖功勋的义务。最后，中国内地和中国港澳台地区的所有中华儿女都共享共同的“文化宪法”，其所负有的爱国义务主要是维护中华民族共同体的道德义务和文化宪法义务。具言之，现阶段我国台湾同胞的首要爱国义务是坚持一个中国原则，即不得分裂国家，并促进祖国和平统一。我国香港特别行政区已经通过的《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全条例》更是全面落实了公民所负有的维护国家主权、统一和领土完整的义务。

2. 基于公民身份的爱国法律义务

充分发挥爱国主义效能，有赖于公民积极履行爱国主义法律义务。公民身份为落实公民的爱国法律义务明确了直接依据。公民身份是公民通过对国家法律和制度的自愿承诺而获得的。^{④3} 在法律义务层面上，爱国主义要求共同体成员负有对国家和同胞的双重关切义务。^{④4} 爱国法律义务具体包括如下内容：一是对实现国家目的的协助义务。国家在行使其职权、履行其职责的过程中需要一定的物质、制度条件，公民向主权国家履行爱国法律义务就是在为国家达成其维护主权的目​​的提供条件。例如，中华人民共和国公民都有服兵役的义务，公民通过服兵役保卫祖国、抵抗侵略就是在履行爱国法律义务。二是延续国家记忆的参与义务。国家符号、国家标志、国家文化、国家历史、国家仪式、国家语言等要素都是国家记忆的组成部分，延续国家记忆是公民永恒的课题。只有推动公民对公共事务的参与，鼓励公民参与并书写国家的历史叙事，共同塑造集体记忆，才能不断增强公民的爱国主义力量。例如，我国《爱国主义教育法》第15至18条预设了不同主体接受爱国主义教育的义务。三是承担消极不作为的底线义务。我国《刑法》设定了公民爱国义务的底线。例如，《刑法》分则第一章规定了背叛国家罪、分裂国家罪等，《刑法》第299条规定了侮辱国旗、国徽、国歌罪。上述内容明确规定了公民有维护国家安全、荣誉和利益的底线义务。

3. 基于特定主体身份的爱国政务义务

爱国政务义务即公职人员基于其特定主体身份而负有的义务。我国公职人员包括公务员和其他公职人员，这体现在《公务员法》《监察法》等法律中。《公务员法》第2条第1款明确了公务员的范围，《监察法》第15条明确了六类监察对象，在这些范围和类别内的主体均负有爱国政务义务。《公务员法》第2条第2款将公务员定性为“人民的公仆”，其中“人民”两个字表明了其鲜明的爱党爱国性质，“公仆”则说明了公务员的工作必须有利于

^{④2} 参见〔美〕汉娜·阿伦特著、杰罗姆·科恩编：《反抗“平庸之恶”》，陈联营译，上海人民出版社2014年版，第56-57页。

^{④3} See Robert T. Schatz, “A Review and Integration of Research on Blind and Constructive Patriotism”, in Mitja Sardoc (ed.), *Handbook of Patriotism*, Springer Nature Switzerland AG Press, 2020, p. 622.

^{④4} 参见吴俊：《爱国何以是一种公民美德》，《哲学研究》2019年第10期，第25-26页。

国家和社会、有利于维护中华民族共同体。此外,《公务员法》第12条第4款明确规定了公务员负有“维护国家的安全、荣誉和利益”的义务。2019年新修订的《公务员法》丰富了公务员的行为规范内容,特别是在第59条第1款和第3款专门增列了关于公务员应履行爱国和维护中华民族共同体的义务的内容,这也是对公务员爱国政务义务的明确表达。《爱国主义教育法》第18条也规定了公职人员主动作为的爱国义务。需要指出的是,我国香港特别行政区、澳门特别行政区关于公务人员任职条件和义务的规定本质上包含了爱国政务义务的内涵。

总之,这三种基于公民的不同身份而划定的不同类型的爱国主义法律义务,可以融通理论分析和实践指导,从而为我国爱国主义领域的依法治理和爱国主义法治体系的构建提供科学依据。

三、爱国主义法治建设的基本样态

改革开放以来,我国在爱国主义法治建设实践方面取得了巨大进展,积累了丰富的制度资源。然而,这些制度资源犹如矿石原石,共生于爱国主义立法、执法、司法及守法等环节之中。因此,有必要对这些“矿石”进行“选矿”处理,即对现有制度资源进行去粗取精。换言之,应加强对现有成功制度经验的借鉴与应用,并有的放矢地对其进行制度补强,这样才能系统、深入地推进我国的爱国主义法治建设。

(一) 爱国主义法律规范体系的功能分类结构模式

我国已经基本形成了一套涵盖维护国家主权和安全、民族团结、国家尊严、国家荣誉及其他国家权(利)益的爱国主义法律规范体系,为爱国主义领域的依法治理打下了坚实基础。从立法功能看,我国爱国主义立法可以分为以下三种类型。

其一,价值引导型爱国主义宪法。所谓价值引导,就是通过《宪法》的根本大法地位,将爱国价值确立为法律体系和公民行为的价值导向。首先,我国《宪法》序言部分多次出现“国家独立”“民族解放”“维护国家独立和安全”“维护民族团结”“爱国统一战线”“实现中华民族伟大复兴”等内容,这些内容为我国《宪法》注入了丰富的爱国主义价值元素,奠定了我国以爱国作为《宪法》及法律秩序的价值基础的总基调。其次,我国《宪法》第24条第2款规定了关于国家为人民开展爱国主义教育的内容,明确了国家开展和促进爱国主义教育的政府职责,从而确保在爱国主义教育过程中能够实现并强化爱国的核心价值。总之,价值引导型爱国主义宪法具有独特作用,它指向“为个体和国家创造一个价值同源的‘公天下’,让国家真正成为一个值得每一个公民去热爱的公共家园”。^④

其二,情感促进型爱国主义法律规范。所谓情感促进,是指通过支持、鼓励、倡导等方式促使公民传承和弘扬爱国主义精神,进而促进或提升公民的爱国主义情感。例如,我国《文物保护法》和《英雄烈士保护法》均在第1条规定了关于传承和弘扬爱国主义教育以及革命传统教育的内容。《爱国主义教育法》是我国目前关于系统性开展爱国主义教育的专门法,其第2条明确规定要通过爱国主义教育活动“培育和增进对中华民族和伟大祖国的情

^④ 秦小建:《精神文明的宪法叙事:规范内涵与宪制结构》,《中国法学》2018年第4期,第43页。

感”。此外,《国防教育法》《高等教育法》《教师法》等法律法规也有丰富的相关规定。

其三,行为规范型爱国主义法律规范。行为规范型爱国主义法律规范旨在通过确立和实现爱国主义法律义务,为将爱国行为纳入法律调整范围提供直接依据。首先,我国《宪法》第50至56条规定了公民的爱国主义基本义务,包括维护国家统一、民族团结、国家安全、国家荣誉、国家利益,保守国家秘密,保卫祖国,服兵役,依法纳税等基本义务。其次,领域法明确了具体的爱国主义法律义务。依据法律载明的不同立法目的,这些领域法可以被分为:第一,以维护国家安全为价值目标的法律,如《反恐怖主义法》《反间谍法》《国家安全法》《出境入境管理法》《网络安全法》等;第二,以维护国家尊严为价值目标的法律,如《国旗法》《国徽法》《国歌法》等;第三,以维护国家主权、统一、领土完整和安全为价值目标的法律,如《兵役法》《国防法》《国防动员法》《国防交通法》《军事设施保护法》《澳门特别行政区驻军法》《香港特别行政区驻军法》等。这些法律为公民依法履行爱国主义法律义务提供了直接法律依据。再次,《刑法》分则通过专章设置了“危害国家安全罪”,《公务员法》和《监察法》等对特定主体(国家公职人员)应当履行的爱国行为予以了规定,二者均为违反爱国主义法律义务的行为划定了法律红线。最后,《爱国主义教育法》第11、12条规定,爱国主义教育管理是人民政府教育行政部门的重要职责,这为政府履行爱国主义教育的相关职责提供了依据。

然而,我国爱国主义法律规范体系也存在一定不足:首先,我国爱国主义法律规范缺乏系统设计,以及缺乏围绕爱国主义内容构造法规范的系统布局。换言之,爱国主义法律规范体系的四梁八柱尚未齐备。其次,我国爱国主义法律义务的可实施性不足。目前,我国爱国主义法律义务的实施主要通过单行法来承接,这导致爱国主义宪法义务被弱化为了普通法律意义上的行政法律责任。可见,爱国主义宪法义务与法律义务之间缺乏协同实施机制。最后,不同的爱国主义法律规范之间缺乏融贯性。涉及相同价值目标的不同爱国主义法律规范在法律位阶、基本原则、规范内容、执行保障等方面尚存在一定冲突,这导致爱国主义法律规范之间的协调性显现不足。以维护国家安全的爱国主义法律规范为例,《国家安全法》在功能和内容上应具有统领国家安全立法的“基本法律”属性,^④然而,其却与《生物安全法》《网络安全法》《数据安全法》等具体领域安全法同属于一般法律,在法律地位和效力上甚至不及《反分裂国家法》(全国人大制定),这种情况造成了国家安全法治体系内部协调性不足的问题。

(二) 爱国主义行政执法的“条块结合”实践模式

目前,我国爱国主义行政执法强调各行政主体应主动履行爱国主义的职权性法定义务。我国爱国主义行政执法具体通过“条块结合”的方式进行。首先,我国行政执法部门在爱国主义教育促进,国家主权、安全及利益维护,国家尊严捍卫等方面发挥主体性作用,形成了由政府相应职能部门分别行政执法的块状“分权模式”。例如,网信部门负责网络安全维护和网络数据监管等方面的法律实施,教育行政部门则负责在学校实施爱国主义教育相关法律等。其次,根据爱国主义的具体事项,我国爱国主义行政执法大致形成了中央部门主管、多部门共同参与、地方各级相应部门按地域和科层分工的“职责(义务)分工+协同”模式。

^④ 参见杨宗科:《论〈国家安全法〉的基本法律属性》,《比较法研究》2019年第4期,第1页。

一方面,上述模式多通过义务性规范得到表达。例如,我国《英雄烈士保护法》第4条第2款规定:“县级以上人民政府负责英雄烈士保护工作的部门和其他有关部门应当依法履行职责,做好英雄烈士保护工作。”另一方面,上述模式亦通过权义复合性规范得到表达。例如,在爱国主义教育工作中,中央爱国主义教育主管部门对地方各级爱国主义教育主管部门的工作负有指导、监督和统筹协调的职责;地方各级爱国主义教育主管部门在中央爱国主义教育主管部门的指导下,对本地区的爱国主义教育负有指导、监督和统筹协调的职责;地方各教育、文化和旅游、新闻出版、广播电视、电影、网信、文物等部门和其他有关部门在各自职责范围内,具体执行和细化爱国主义教育的相关内容。

但是,我国爱国主义行政执法已然面临如下问题:第一,爱国主义行政执法存在权力空白问题,既有法律规范规定的行政主体的行政职责不足以规制复杂多样的涉爱国主义违法行为。例如,《爱国主义教育法》第12条和《英雄烈士保护法》第17、27条均规定了人民政府的教育行政部门具有组织、协调、指导和监督学校爱国主义教育工作的职责,但是这些规定只是针对爱国主义教育的原则性和组织保障性规定,并没有明确相关部门在学校爱国主义教育工作中预防、规制涉爱国主义违法行为的法定职责。此外,教育系统内出现的丑化抗日战争、问题教材等事件,均是在网络发酵后才引起人们的关注,事前并没有行政执法部门对这些事件予以风险排查和规制。可见,我国亟待设立专门负责落实、监督学校爱国主义教育工作的行政执法部门。第二,爱国主义行政执法存在权力重叠问题。这主要表现在两个方面:首先,爱国主义行政执法依然面临“条块冲突”的问题,即各行政执法部门权责不一致,有职权的部门不承担执法责任,对综合执法的依赖性较大等问题。^{④7}其次,行政执法部门的职责范围重叠,但是履职模式相对分离。既有规范对各部门之间的协同方式、职责分工等内容规定尚不明确。关于协同执法模式如何启动,各部门之间的执法怎样衔接、权责如何配置、监管如何配套等关键问题均不能从现有的制度和实践层面找到明确答案,这在实践中可能导致行政部门以利益为导向进行选择性的执法。

(三) 爱国主义司法保护的“私权保障辐射型”模式

当前,我国司法机关主要通过如下四种方式实现对爱国主义的司法保护。

第一,通过出台司法文件,引导司法活动践行和弘扬社会主义核心价值观和爱国主义精神。例如,为促使各级人民法院在工作中践行社会主义核心价值观,最高人民法院出台了《关于在人民法院工作中培育和践行社会主义核心价值观的若干意见》,旨在将爱国主义精神贯彻到各级人民法院的工作中。又如,为通过审判工作保护红色经典和英雄烈士合法权益,2018年,最高人民法院发布了《关于加强“红色经典”和英雄烈士合法权益司法保护弘扬社会主义核心价值观的通知》,积极推进爱国主义司法保护工作。此外,2021年,最高人民法院印发了《关于深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理的指导意见》,力图把爱国价值准则融入裁判文书的说理部分。

第二,通过在个案裁判的过程中发挥社会主义核心价值观的指引、示范功能,从而在维护私权利的过程中保护爱国主义。例如,在楼某熙诉杜某峰、某网络技术有限公司肖像权纠纷案中,行为人于“七七事变”84周年纪念日在微博上发表不当言论,并将带有他人脸部

^{④7} 参见陶振:《基层治理中的条块冲突及其优化路径》,《理论月刊》2015年第1期,第102页。

的清晰照片附于其发表内容中，意图达到贬低、丑化中国人的目的。法院认为，这种行为侵犯了他人肖像权和社会公共利益，因此，该行为人应承担民事侵权责任。^{④⑧}由此可见，司法通过保护私主体的肖像权、名誉权等私权利，同时附带保护了依附在该私权利外观形态上的爱国主义精神。

第三，通过民事公益诉讼的方式，对爱国主义进行司法保护。例如，在瞿某某侵害英雄烈士董存瑞名誉权民事公益诉讼一案中，法院认为，英雄烈士用鲜血谱写了伟大的爱国精神，尊重英雄烈士是社会主义核心价值观的重要体现。瞿某某在网上销售亵渎英雄烈士的贴画的行为不仅侵害了烈士的名誉权，也损害了公众的民族感情以及社会公共利益，因此，其应当依法承担民事法律责任。^{④⑨}

第四，通过严格的刑事司法，严惩背叛国家犯罪、分裂国家犯罪等危害国家安全和社会稳定的犯罪行为，从而实现对国家利益的保护。根据保护法益的不同，我国《刑法》中关于违反爱国主义的罪名可被分为三类：一是危害国家安全类犯罪。这类罪名所保护的法益是国家安全，即国家政权、主权、统一和领土完整等国家重大利益不受内外威胁的状态。此类犯罪主要包括危害国家、颠覆政权的犯罪，叛变、叛逃的犯罪和间谍、资敌的犯罪。二是危害国防利益类犯罪。该类罪名保护的法益是国防利益，即国防活动能顺利进行的正常状态及国家安全利益。根据侵害对象的不同，可以将此类犯罪分为妨害军事行动罪，战时拒绝、逃避服役罪等。三是扰乱公共秩序罪中涉及侵犯政治公共秩序的犯罪，包括侮辱国旗、国徽、国歌罪和侵害英雄烈士名誉、荣誉罪等。

虽然我国司法机关通过不同的模式实现了对爱国主义精神的保护，但这些模式均可被概括为“私权保障辐射型”模式。这种模式对爱国主义精神的保护依附于对个人私权利（如个人的肖像权、英雄烈士的名誉权等）的保护之上，这导致爱国主义司法保护出现了如下问题：第一，应当如何保护不依附于英雄烈士的名誉权、肖像权等私权利之上的爱国主义公共利益？能否单独依据爱国主义公共利益提起民事公益诉讼？第二，司法介入爱国主义保护的范围和限度不够明确，影响了司法救济的效果。第三，与爱国主义相关的司法政策供给不足。由于爱国主义具有多种行为内涵和很强的精神属性，不可能也不应该将其全部纳入法律的强制性规定之中。因此，应当将爱国主义纳入司法政策的考量范围之中。然而，虽然司法政策之于爱国主义相关案件的审判具有重要的指导和规范作用，但是我国的爱国主义司法政策主要体现在贯彻社会主义核心价值观的相关司法政务文件中，这影响了爱国主义司法保护的效果。

（四）爱国主义守法的实践强化模式

实现“内心遵从”与“行为践习”的结合是强化爱国主义守法机制的关键，爱国主义教育和爱国主义公共实践共同构成了爱国主义守法机制的核心内容。

首先，加强爱国主义教育激发公民爱国主义精神的内生动力。加强爱国主义教育的方式包括：第一，强化爱国主义教育组织形式。例如，《爱国主义教育法》第13至22条规定了面向群团组织、家庭、学校、政府机关、行业团体、自治组织、宗教团体等不同群体所应

^{④⑧} 参见人民法院贯彻实施民法典典型案例（第一批）之七。

^{④⑨} 参见浙江省杭州市互联网法院民事判决书，（2019）浙0192民初9762号。

开展的爱国主义教育。第二，丰富爱国主义教育内涵。例如，《爱国主义教育法》第6条规定了爱国主义教育的主要内容包括党和国家的指导思想教育、“五史”教育、中国特色社会主义制度及实践教育、“三类文化”教育、国家象征及标志教育、自然和历史文化遗产教育、宪法法律秩序教育、国家统一教育、民族团结教育、国家安全及国防安全教育、英烈事迹和精神教育等。第三，拓展爱国主义教育的实施方式。例如，通过举办烈士纪念活动和纪念仪式、开展重要节日活动和民俗文化活动等方式宣扬爱国主义精神；通过在组织重大活动（如宪法宣誓、服役宣誓）时举行升挂国旗、奏唱国歌仪式，制作、播放、刊登爱国主义题材优秀作品，发布爱国主义公益广告等方式宣扬爱国主义教育。

其次，爱国主义公共实践是培养公民爱国主义精神的根本依托。爱国主义公共实践具体包括：第一，公民依法履行爱国主义法律义务。例如，公民在日常生活中积极履行维护国家统一、安全、荣誉、利益，保守国家秘密，服兵役，依法纳税等义务。第二，加强公共网络空间的爱国主义教育。第三，支持爱国主义行动。例如，在国家统一、领土完整，国家尊严、安全或其他重大利益遭受严重侵害的事件中，公民依法采取（如游行、示威、抵制等）群体性行为表达对国家的支持或情感。

但是，爱国主义守法机制仍存在如下问题：第一，针对盲目爱国主义行为所引发的社会风险的防范和化解机制不足。盲目爱国主义行为即以爱国主义为策划与包装，有意通过公共事件设置公共议题，操弄、裹挟公共舆论，凭借道德审判压制个体权利和自由表达空间的行为。第二，爱国主义参与的正向牵引作用有待加强。第三，爱国主义的包容性发展略显迟滞。爱国主义的包容性要求尊重个人的主体性表达，在个人不违反爱国主义法律规范强制性规定的前提下，不得擅自提高对个人爱国主义的道德标准。此外，对于市场主体（公司或其他组织）的合法市场行为，不得以爱国主义的名义对其肆意“绑架”。当下，扛爱国主义大旗对个人或市场主体肆意攻讦、挞伐的行为，严重侵蚀了爱国主义包容性发展的共识性基础，侵害了爱国主义宪法制度的严肃性和权威性。

四、爱国主义法治建设的系统推进

爱国主义法治体系包括爱国主义立法、执法、司法、守法等环节，完善爱国主义法治体系需要着眼于这些环节，从而有的放矢，系统、协调地提升爱国主义法治建设水平。

（一）健全爱国主义法律规范体系

针对我国爱国主义法律规范缺乏系统性和协调性，以及爱国主义法律规范的供给能力有待提升等问题，可以通过构建“基础法+专门法+相关法”的结构模式健全爱国主义法律规范体系。

第一，明确爱国主义基础法，以基础法统领爱国主义法律规范体系。爱国主义法治建设的根本目的是巩固国民爱国情感，强化国民身份认同，形成社会主义现代化强国的强大精神力量，而基本法的首要功能是明确爱国主义法律规范的价值目标。鉴于目前我国爱国主义法律规范体系存在体系化不足、内部结构松散、系统协调性欠缺等问题，因此，亟待制定上承国家宪法共识，下达爱国主义法律规范体系的爱国主义基础法。可以通过从既有的爱国主义法律规范中抽离并凝练爱国主义法的基本概念、立法宗旨和原则、适用范围和主体、规范内

容等，建构爱国主义法律制度基本框架。

第二，健全爱国主义专门法，以专门法开辟爱国主义法律规范体系运行的基本领域。由于涉及爱国主义内容的法律规范较为繁杂，因此，需要以类型化的方式对这些法律规范进行分类并构建以领域为标识的专门法。爱国主义专门法的领域划分应当遵循密切相关原则，即从社会公众的一般认知视角确定与爱国主义内容关联程度较高的相关领域。目前，与我国爱国主义内容关联程度较高的领域主要包括爱国主义精神的促进或生发、国家标志的保护、国家安全的维护等。与此相对应，爱国主义专门法体系主要由爱国主义精神促进法、国家标志法、国家安全法等法律群组成。同时，每个法律群又囊括多个爱国主义法律规范，如国家标志法包括《国旗法》《国徽法》《国歌法》等。通过领域法的立法思维完善爱国主义专门法，不仅可以对现有的爱国主义法律规范体系范围进行框定，从而确定爱国主义主体的权利义务关系，还可以加深公众对爱国主义法律规范体系的深入理解。总之，健全爱国主义专门法有利于为爱国主义法律规范体系的有效运行提供规范基础。

第三，推动出台爱国主义相关法律，为发展爱国主义法律规范体系提供配套规范，增强爱国主义基本法和专门法的可操作性。具体而言，应当把爱国主义精神融入相关法规和政策之中，并将爱国主义内容转化为具体的法律义务或社会行为规范要求，通过不同层次的规范发挥爱国主义的倡导作用，增强公民爱国主义法治观念，塑造公民正确的爱国观。例如，《长沙市文明行为促进条例》第6条第2款规定，“倡导向雷锋等英雄模范学习，崇尚英雄模范，传承、弘扬英雄模范精神”。该条规定强调了对爱党爱国精神的传承与发扬，是对公民文明行为的总体要求。再如，《长沙市民文明公约及行为守则》将“爱国爱家”放在首位，这一举措为具体法规条文注入了爱国主义精神，使“爱国”成为普遍行为规范。

（二）构建刚柔并济的双层爱国主义行政执法机制

爱国主义法治建设着力于对公民爱国主义情感的促进以及对公民爱国行为的规范。对公民爱国主义情感的促进侧重于强调国家或相关组织对公民的教化职责；对公民爱国行为的规范侧重于对以爱国主义为价值导向的，对国家安全、健康存续及良好发展状态不受威胁等利益存在重大影响的相关行为的规制。因此，应根据促进公民爱国主义情感和规范公民爱国行为这两项举措各自所遵循的内在逻辑差异，分类完善爱国主义行政执法部门的义务内容。

第一，爱国主义行政执法部门应积极履行倡导性义务，实现对公民的爱国主义教育。爱国主义教育的逻辑前提是，承认公民对国家道德教化的可接受性以及公民与国家进行双向沟通的可能性。公民本身不仅是接受爱国主义教育的对象，也是爱国主义教育的重要参与主体。充分尊重公民的爱国主义教育主体地位，以普通公民“可理解、可接受、可遵循”为原则创新爱国主义教育方式，畅通爱国主义教育路径，激发公民参与爱国主义教育的热情，是确保爱国主义教育取得实效的关键。我国《爱国主义教育法》明确了爱国主义教育的内容包括思想政治教育、历史文化教育、宪法法律教育、民族团结和国家统一教育、国家安全和国防教育、民俗文化活动教育等，这些都是爱国主义倡导性义务的涵盖范围。基于此，相关行政执法部门需要提高其公共服务的能力，积极履行爱国主义倡导性义务。例如，应严厉禁止和纠正在大山大河旁修筑围墙的错误行为，这些做法阻碍了公民在感受祖国壮美河山的过程中提升自豪感和家国情怀。此外，需要加强诸多非传统教育部门（如宣传、广电、网信、民政等）之间的跨部门协作，并将政府部门、企业、群团组织和公民协同起来，从而促

进爱国主义倡导性义务的实现。

第二,爱国主义行政执法部门要严格实施强制性义务,对涉爱国主义违法行为进行制裁。我国《英雄烈士保护法》《文物保护法》等法律规定了针对侮辱、诽谤英雄烈士的姓名、肖像、名誉,侵占、破坏英雄烈士纪念设施等违反爱国主义行为规范的行为的处罚措施,主要包括治安管理处罚和追究刑事责任。需要强调的是,爱国主义强调共同善和整体主义,这意味着需要处理好爱国主义与个人权利和自由的边界。^⑤基于对公民个体权利和自由的保护,制裁公民涉爱国主义违法行为必须以法益保护为依据。因此,应严格把握涉爱国主义违法行为的入罪入罪标准,即应以英雄烈士私人权益和爱国主义公共利益是否受到侵犯为标准设定公民爱国行为规范。此外,应加强对行政执法部门不作为、乱作为的监督,明确相关法律责任。

(三) 拓展“上下联动”的爱国主义司法保障机制

针对爱国主义司法保护中的制度供给不足问题,应当构建“自上而下”和“自下而上”的双向爱国主义司法保障机制,进而强化爱国主义司法保障的功能。

第一,构建“自上而下”的爱国主义司法保障机制。首先,应适度拓宽爱国主义公益诉讼的保护领域。目前,我国《英雄烈士保护法》第25条规定了爱国主义公益诉讼的保护领域,即检察机关可以对“侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的行为”提起民事公益诉讼。但保护英雄烈士仅仅是爱国主义涉及的内容之一,爱国主义涉及的其他内容尚游离在公益诉讼的法定“保护域”之外。因此,适度拓宽爱国主义公益诉讼的保护领域是司法进一步介入爱国主义保护的必然选择。但需要强调的是,对拓宽爱国主义公益诉讼保护领域这一举措应持审慎态度。首先,应在对爱国主义领域内的违法行为类型化,且使其达成社会广泛共识的基础上,稳步推进爱国主义公益诉讼,实现爱国主义公共利益保护和公民个体权利及自由保护之间的均衡,从而避免公益诉讼沦为爱国主义极端化的危险利器。其次,应制订促进爱国主义依法保护的司法政策,注重以爱国主义司法政策的方式指引司法实践、明确法律适用思路。此外,应通过出台规范性文件或司法解释向社会释放促进爱国主义依法保护的明确信号,为全国各级法院办理涉爱国主义案件和开展爱国主义保护工作提供清晰明确的指引,督促相关主体理性、科学实施符合爱国主义要求的相关行为,切实履行法定职责,从而从根本上预防爱国主义走向极端化,保障公民的合法权益和促进爱国主义健康发展等。最后,司法机关应发布涉爱国主义保护的指导性案例或典型案例,通过以案释法,发挥案例在爱国主义保护宣教上的特殊作用,从而实现爱国主义在法律效果和社会效果上的统一。

第二,构建以诉讼为基点的“自下而上”的爱国主义司法保护机制。首先,应确立“公益保留原则”,严格限定私主体基于爱国主义事由提起的个案诉讼。目前,我国司法实践对私主体基于维护公共利益的目的提起的民事公益诉讼持审慎态度(仅限于法律规定的特定领域),这种态度主要基于对私主体无法代表公共利益的隐忧和考量。爱国主义涉及的保护领域多关涉公共利益,若允许私主体以爱国主义的事由或名义提起诉讼(即以私主体代表公

^⑤ 参见朱慧玲:《爱国主义的双重维度——基于公民共和主义的证成与辩护》,《哲学研究》2019年第10期,第35页。

共利益行使诉权),势必会为爱国主义的庸俗化、极端化打开“潘多拉魔盒”。例如,近来某网络博主以著名作家莫某的作品涉嫌“抹黑先烈”为由提起诉讼的荒唐闹剧即明证。其次,应恪守“司法谦抑原则”,严格落实涉爱国主义违法犯罪案件的线索移送制度,司法机关对在诉讼过程中发现的案件线索,应当及时对其采取必要的保护措施,并将其移送至相应的司法机关或行政机关。

(四) 以“防范风险+完善激励+包容发展”为支点健全爱国主义守法机制

在制度层面补强爱国主义守法资源是增强爱国主义实效性的保障。以“防范风险+完善激励+包容发展”为支点构建爱国主义守法制度,从而形成制度合力,能够有效解决守法领域难点问题、增强公民爱国主义守法意识。

第一,构建爱国主义风险防范机制,实现对盲目爱国行为所引发的潜在危机的有效管控。从渊源上论,盲目爱国主义脱胎于爱国主义但不属于爱国主义,是一种“伪装”的爱国主义。盲目爱国主义以爱国主义为策划和包装,消费人们朴素的爱国主义情感,进而攫取公众流量、操弄公共舆论和撕裂社会共识。构建爱国主义风险防范机制,就是要提醒公民时刻保持对盲目爱国主义的自省和警惕,提高精准识别能力,科学评估盲目爱国主义的危害后果。此外,相关部门应设置相应的处置措施,积极防范和化解爱国主义的潜在风险,为创建良好的爱国主义守法业态提供保障。

第二,完善爱国主义守法激励机制,扩大公民参与爱国主义的范围和程度。首先,应通过对爱国行为的积极评价,发挥爱国主义的正向激励作用。例如,应强化对英雄烈士的保护与奖励,“扩大《英雄烈士保护法》对英雄烈士范围的认定。英雄烈士不仅仅指近代战争中牺牲的英雄烈士,也包含了当代的英雄烈士”。^{⑤1}其次,应当将爱国主义内容设置为某些特殊行业群体获取从业资格的前置条件。例如,可以将爱国主义内容吸收进《公务员法》《教师法》《征兵工作条例》等之中,并将其作为特定群体获取从业资格的前置条件。最后,需要建立健全对“恨国”行为的惩罚机制。如衔接《刑法》《网络安全法》《网络安全审查办法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网新闻信息服务管理规定》中的相关规定,完善对煽动网络仇恨等违法行为的惩罚机制。

第三,以“包容性”赋能爱国主义法治文化,推动爱国主义的包容性发展。一方面,应在爱国主义教育中着力培育富含“包容性”的爱国主义法治文化。我国《爱国主义教育法》第9条对爱国主义教育应坚持包容性作了规定。“包容性”既是爱国主义的应有属性,也是开展爱国主义教育应遵循的原则和方法。“包容性”强调开放、宽容和接纳,反对封闭、狭隘和排斥,其本质是宪法“共和”精神的体现。以“包容性”赋能爱国主义法治文化,可以提升守法者爱国主义的境界和守法能力,化解盲目爱国主义的“冲动和戾气”,让爱国主义回归理性。另一方面,应当在爱国主义公共实践中着力纠偏盲目爱国行为。政府部门应当积极作为,摒弃对盲目爱国行为放任或放纵的态度。有关主体在不违反爱国主义法律规范强制性规定的前提下实施的盲目爱国行为,政府部门应及时对其予以纠偏。

^{⑤1} 杨清望:《国家客观文化法益的法理分析及其法律保护——以英雄烈士权益保护为切入点》,《法制与社会发展》2022年第4期,第53页。

结语：以法治轨道牵引理性爱国

习近平总书记指出：“爱国主义是中华民族精神的核心。爱国主义精神深深植根于中华民族心中，是中华民族的精神基因，维系着华夏大地上各个民族的团结统一，激励着一代又一代中华儿女为祖国发展繁荣而不懈奋斗。”^{⑤②} 弘扬和传承爱国主义精神不仅是每个中华儿女义不容辞的责任，更是其法律义务。放眼世界，爱国主义是政治哲学和道德哲学领域历久弥新的重要话题。可以说，国家作为人民放置安全感的依托，从产生伊始就内在地要求人民的忠诚和服从。然而，忠诚和服从又必然会引起公民排他性的冲动乃至行动，这不仅是逻辑上的两难，更是现实中的艰难抉择。因此，如何处理好忠诚和服从国家与防止盲目爱国主义之间的关系，以及如何处理忠诚和服从国家与保护人的权利和尊严之间的关系，是世界各国都面临的两大难题。尽管西方的宪法爱国主义、温和爱国主义等理论的提出也是对解决这两大难题的有益尝试，但是囿于西方国家在意识形态上的定见和迥异于中国政治文化传统的实际，其解决方案必然具有偏狭性，甚至会形成自由主义至上的偏见。由此可见，结合中国实际推进理性爱国主义已经成为必然选择。加强爱国主义法治建设既是传承和弘扬爱国主义精神、发挥爱国主义巨大精神动力的根本保证，也是确保爱国行为不悖离文明发展的“定海神针”。由此，爱国主义法治建设需要在“国家、社会、个体”的关系中，实现各方权利义务的平衡：一方面，国家要保障公民的个人权利，维持社会的活力；另一方面，国家应确立冒犯公众爱国情感和国家意识形态法益的底线，对违法行为进行规制，但同时必须防范将盲目、狭隘的爱国主义作为价值正确，恪守公权力介入爱国主义法治的谦抑性。从国家的角度来说，必须全面推进爱国主义法治建设，加强国家目的和国家能力建设，通过法治凝聚爱国主义的价值共识，为爱国奠定深层动力之源。恰如黑格尔所言，只有一方面承认和发展普遍性共识和价值，另一方面有助于实现充分而活泼的发展，国家才能被看作一个肢体健全的和真正有组织的国家。^{⑤③} 从爱国主体的角度来说，这要以爱国主义法律义务的落实为支点，明确政权机关、社会和个体的职责、义务，推动爱国主义从道德要求适当向倡导性、强制性义务转变；同时用法律弥合不同主体之间的分歧，发挥法律对爱国主义的引导、保障和促进作用，推动爱国主义长效化、制度化。当然，全球化的发展、互联网和 AI 等科学技术的发达，正在冲击着国家的边界和国家共同体意识，因此，爱国主义法治建设是一个未尽的话题，必须与时俱进，对其展开更加深入的研究。

Abstract: Inheriting and carrying forward the spirit of patriotism according to law is the inevitable requirement for promoting people's national identity, and it is also an effective guarantee for the realization of rational patriotism. "China" is a synthesis of historical culture and political-legal con-

⑤② 习近平：《大力弘扬伟大爱国主义精神，把强国建设、民族复兴伟业不断推向前进》，《求是》2024年第19期，第7页。

⑤③ 参见[德]黑格尔：《法哲学原理》，范扬、张企泰译，商务印书馆2011年版，第277页。

cept, and it provides deep cultural roots and realistic legal basis for people's patriotism. The legal connotation of patriotic acts includes the acts of preservation, obedience and participation. Strengthening the construction of the legal system of patriotism has a profound legal basis and institutional resources. On the one hand, the legal obligation of patriotism defines the content and boundary of patriotic behavior. On the other hand, legislation, law enforcement, justice and law-abiding have accumulated rich practical experiences, but there are also many deficiencies. Currently, we can improve the legal system of patriotism through the structural model of basic law, special law and relevant law, aiming to improve the construction of patriotic legal system. Still, it is necessary to build a rigid and flexible administrative law enforcement mechanism. Moreover, we should actively expand the judicial protection system for patriotism characterized by "top-down linkage". Meanwhile, we can establish a law-abiding mechanism for patriotism based on risk prevention, improvement of incentives, and inclusive development. Finally, the institutional synergy is formed to realize the orderly and healthy development of patriotism.

Key Words: Patriotism; Construction of Rule of Law; Legal Obligations; Institutional Resources; Enforcement System

[责任编辑:朱 振 李 好]